

1500648-85.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... o local é um conhecido ponto de tráfico; que era um frasco cilíndrico com batatas.

Já a testemunha Serafim Matheus de Oliveira (policial militar) afirmou que estavam em patrulhando quando avistaram um indivíduo próximo às casas populares, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo que esse indivíduo apresentou certo nervosismo e caminhou em disparada ao fundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista - SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500648-85.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500648-85.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODRIGO DE JESUS DE SOUZA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de Rodrigo de Jesus de Souza Silva, na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33 da Lei n. 11.343/06..

Narra-se na denúncia que "no dia 10 de junho de 2021, por volta de 23h20, na Rua João Dubs, altura do n. 280, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista/SP, RODRIGO DE JESUS DE SOUZA SILVA, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 10 (dez) porções de maconha, pesando aproximadamente 23,0g, 33 (trinta e três) porções de crack, pesando aproximadamente 19,0g, e 114 (cento e quatorze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 109,0g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

A denúncia foi recebida em 27/09/2021.

Notificado, o denunciado apresentou resposta à acusação (fls. 118).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a

absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3), pelo laudo de exame pericial (fls. 88/90), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Alisson Francisco de Oliveira (policia militar) relatou que se recorda vagamente da ocorrência; que estavam de serviço em Perdões e durante patrulhamento do local; que em um corredor de casas populares fizeram abordagem do acusado e nada de ilícito foi localizado em suas vestes; que ele estava com um frasco de batatas e dentro dele localizaram crack, maconha, cocaína e uma quantia em dinheiro; que ele alegou que era para uso próprio; que então o conduziram à delegacia de plantão, de Atibaia; que já havia o abordado anteriormente, mas sem localizar nada de ilícito com ele; que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas; que quando o visualizaram ele estava caminhando para o fundo da viela; que quando o viram, ele não tentou fugir, colaborou a todo momento com a abordagem; que as drogas foram localizadas em um frasco de batata, salvo engano verde; que havia pouco dinheiro, salvo engano setenta reais; que o frasco estava na mão do réu; que no local, como é de casas populares, diversas pessoas saíram pela via ao ouvir a abordagem; que o acusado estava sozinho ao ser abordado; que o abordaram porque o local é um conhecido ponto de tráfico; que era um frasco cilíndrico com batatas. Já a testemunha Serafim Matheus de Oliveira (policia militar) afirmou que estavam em patrulhando quando avistaram um indivíduo próximo às casas populares, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo que esse indivíduo apresentou certo nervosismo e caminhou em disparada ao fundo dessas casas; que foi possível observar que na mão do indivíduo havia um frasco verde parecido com o de batata Ruffles; que esse indivíduo caminhou até o fundo dessas casas e o abordaram; que solicitaram apoio da viatura que estava no município em razão de o local ser ponto de tráfico e frequentado por usuários de entorpecentes; que nada localizaram em revista policial, mas no frasco localizaram porções de maconha, crack e cocaína, mais setenta reais em dinheiro; que, indagado, ele confessou o tráfico; que era um frasco verde, meio cilíndrico, e todas as drogas estavam nesse frasco, e o dinheiro também; que ele olhou para um lado e outro e saiu em caminhada rápida em direção às residências; que não havia outras pessoas no momento da abordagem e, depois da abordagem, saíram várias pessoas que ouviram a abordagem; que ele só era conhecido de vista; que ele saiu em rápida caminhada para os fundos e confessou o tráfico pelo local.

Por fim, o acusado Rodrigo de Jesus de Souza Silva, em interrogatório, expôs que no dia dos fatos, uma quinta-feira à noite, sua mãe ligou para si; que sua família é de Franco da Rocha; que sua mãe havia ligado falando que sua irmã havia saído da maternidade e não estava conseguindo fazer ligação de vídeo; que explicou a ela que a cota diária estava extrapolada; que disse que tinha a senha do wifi do CRAS e foi ao local para conectar, ligou para ela, fez chamada de vídeo, havia pessoas em ponto de ônibus; que a viatura passou e o abordou; que desligou o telefone, os policiais o trataram com respeito e educação, perguntaram o que ele estava fazendo; que o local realmente é conhecido como ponto de tráfico, então disse que estava usando o wifi e que morava na casa número 5; que disse que poderia pegar o RG na casa; que disse que tinha passagens pela polícia, então pediram para que ele deitasse no chão; que foi encontrado um pote verde dentro da lixeira; que as pessoas que faziam tráfico no local escondiam droga nas proximidades; que já chegou até a discutir com outras pessoas por causa disso porque tinha passagens na

polícia; que já estava pensando em sair dali por já ter problemas com a justiça e morar em um local assim; que a polícia não o agrediu, mas já pediu para que sentasse no chão; que quando a droga apareceu disse que se não tivesse o dono ele seria o dono, porque eles queriam informação; que não sabia essas informações, então veio preso; que em sua mão só tinha seu aparelho celular; que eles reviraram seu celular e só havia fotos de seu trabalho; que propôs aos policiais a apreensão de seu celular; que a polícia já havia o abordado antes quando havia chegado em casa; que nessa vez foi abordado também pelo policial que fez a primeira abordagem; que o outro policial nunca o abordou; que nessa primeira abordagem não foi indagado sobre passagens; que as pessoas que estavam lá eram Gabriel, de 16 anos, a sua namorada Veronica, bem como Vanderlei, vulgo "Neguinho"; que seus vizinhos são Elaine, Rodrigo e Richard, bem como a mãe de Elaine e saíram para ver a abordagem; que a droga foi encontrada depois que essas pessoas chegaram lá; que o Instagram é "rdartes"; que o celular que usava na época está com a sua esposa e concorda com a revista do celular neste processo.

Já a testemunha Carolina Gianele Gonçalves relatou que é nora do acusado; que ligaram para ela porque iria dar a notícia de que seria avó; que, nisso, a mãe de Rodrigo ligou para ele para dizer que sua irmã iria ganhar bebê; que ele disse que iria à praça para usar a internet do CRAS; que continuaram em casa, ouviram vozes alta, saíram para fora, Rodrigo estava sentado no chão, um policial na frente, e outro andando na praça; que um dos policiais passou por perto de uma lixeira, tirou um pote de dentro da lixeira e foi para perto de Rodrigo; que já tinham dado voz de prisão para ele; que então levaram ele; que Rodrigo estava acabando de fazer uma tatuagem na sua sobrinha; que conhece Elaine, Richard, eram os vizinhos que moram lá, das casas populares; que mora em Francisco Morato e neste dia estava em Perdões, tinha ido no domingo por conta da notícia, e na quinta-feira aconteceu isso; que a notícia era que a companheira de Rodrigo está grávida; que já tinha ido algumas vezes na casa dele e foi junto com sua sobrinha passar a semana lá; que é mãe de Thainara Gonçalves de Lima; que já estava escuro na hora e não sabe se ele lembrou que ela estava lá ou se a viu; que não chegaram a ir à delegacia, só foram até a praça; que eles pediram para que acompanhassem até a delegacia e então só foi Jacqueline; que havia dois policiais e se recorda mais ou menos que era um moreno e um branco e não se lembra qual foi até a lixeira, até porque já era noite; que estava ela, sua sobrinha, a mulher dele e os dois policiais; que além da família tinha um pessoal passando pela rua, andando pela praça, devia ser moradores, que não conhece, pois não mora lá; que com Elaine, Richard tem amizade, mas eles deviam estar por dentro da casa; que não os viu, ficou nervosa de ver aquela cena; que sua filha ficou passando mal; que ao ir ao CRAS ia falar com a mãe dele; que não sabe se ele fez essa ligação; que ficou a uma distância de uma rua; que o pote era verde escura, comprido, como se fosse aqueles potes de batata Ruffles; que ele estava tatuagem no braço de sua sobrinha, na casa dele, isso já à noite; que ele não terminou a tatuagem, é como se fosse uma asa, tipo uma borboleta com asa.

Já a testemunha Jaqueline Alencar Gonçalves Marcondes de Arruda relatou que foram para a casa dele e ele ficou de fazer uma tatuagem em seu braço; que sua tia foi receber a notícia de que a esposa dele estava grávida; que sua tia a chamou para ir para lá, porque queria fazer a tatuagem; que ele fez a sua tatuagem, mas ele não terminou, é uma borboleta; que por volta de umas 23h a sua mãe estava ligando falando que a irmã dele estava saindo da maternidade; que ele estava sem wifi e disse que iria à praça para fazer videochamada e disse que ia voltar depois para terminar a tatuagem; que ouviram um barulho de voz alta e achavam que Rodrigo estava brigando na rua; que então se depararam com Rodrigo sentado, um policial com ele, e outro policial caçando algo; que o policial procurou debaixo de banco, matinho, e quando mexeu em uma lixeira achou um pote de batata lá dentro, tipo de Elma Chips, cebola, e deu voz de prisão para Rodrigo; que sua prima começou a passar mal, sua tia ficou nervosa também; que perguntaram ao policial o porquê, e só falou que iria levar ele; que foi a primeira vez que veio para Perdões; que não conhece os vizinhos, não tem contato; que, na rua, tinha mais gente que viu essas cenas, mas não falou com essas pessoas, não conhece; que sua prima pediu para ir à delegacia, pararam um carro para irem lá; que, no meio do caminho, ela passou mal e

o moço as deixou perto do hospital; que sua prima não quis ficar no hospital, então voltaram para casa e ficaram lá; que só ficou dentro de casa com ela; que não sabe se Rodrigo a viu, não prestou atenção; que o policial falava para ele não dizer nada; que não sabe se Thaynara foi pega com droga em maio de 2021; que não se lembra das feições dos policiais, mas o que estava na frente de Rodrigo era branquinho e gordinho, baixinho, e o outro era moreno alto; que escutou o policial dar voz de prisão e dizer que o que ele falasse seria utilizado contra ele na Justiça; que o policial que disse isso foi o que veio com o pote; que não conseguiu socorrer nenhuma; que Thaynara não quis ir para a delegacia.

Verifica-se, pois, que o depoimento dos policiais é uníssono quanto à abordagem do acusado em via pública em posse de um pote de batata do tipo Ruffles em cujo interior havia droga. Há realmente contradições pontuais entre os depoimentos, tendo em vista que um policial afirma que o acusado não fugiu, ao passo que outro afirma que o acusado passou a adotar caminhada rápida ao ver os policiais, o que pode ser resumido, porém, a uma simples divergência de interpretação de um mesmo fato. Não há contradições substanciais e relevantes que indiquem que houve falsidade dos relatos dos policiais ou mesmo formação de falsas memórias. Os policiais ainda expuseram em juízo que diversas pessoas saíram pela via ao ouvir a abordagem, conforme fora relatado pelo acusado em interrogatório, o que torna reduzida a probabilidade de que, em tal contexto (observados por terceiros), deduziriam relato falso em juízo acerca da dinâmica da abordagem.

Quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

De todo modo, vale notar que, diante da hipótese alternativa ventilada pelo acusado, foi deferida a oitiva das testemunhas de defesa que viriam a ser arroladas pelo acusado, mesmo diante do requerimento intempestivo, tendo em vista estar assistido por advogado nomeado. Não obstante, sobreveio o requerimento de oitiva de Carolina e Jacqueline, ambas familiares, e de nenhum dos populares (sem vínculo de parentesco com o réu) que teriam presenciado a abordagem e poderiam fornecer um relato imparcial sobre o ocorrido.

O relato das testemunhas possui reduzido valor probatório, em razão de lacunas e omissões que retiram a credibilidade de sua versão. A testemunha Carolina expôs que Jacqueline foi à delegacia acompanhar o acusado após a prisão que tiveram por injusta, mas Jacqueline afirmou que não foi à delegacia, pois iria ao hospital com Thaynara, companheira do acusado, e acabou nem mesmo indo ao hospital, pegou carona com um desconhecido e voltou para casa (onde Carolina já estava, logo saberia que

Jacqueline não foi à delegacia, ao contrário do que afirmou em juízo). De todo modo, além das contradições internas entre os relatos, é pouco verossímil que três familiares do acusado, mais os vizinhos com quem nutrem relação de amizade (Elaine e Richard, de acordo com Carolina), tivessem presenciado a prisão injusta e ninguém tivesse ido à delegacia para prestar depoimento ou mesmo noticiar o abuso que haviam acabado de presenciar à autoridade policial.

Nesse rumo, vale destacar que, ao ser instada a dar características dos policiais, a testemunha Caroline deu resposta vaga, dizendo apenas que um seria branco e outro moreno, sem dizer o que cada um fez. Justificou a falta de informações pelo fato de estar nervosa e ser já o período da noite. Contraditoriamente, porém, conseguiu indicar qual seria a marca do pote de batatas que o policial encontrou dentro da lixeira (Ruffles). O contraste entre a vagueza e o extremo detalhamento do relato sobre fatos percebidos na mesma ocasião, à mesma distância e sob as mesmas condições, reduz a sua fiabilidade.

Por fim, chama atenção o relato da testemunha Jacqueline ao afirmar em juízo que ouviu o policial militar dizer ao acusado que "tudo que ele dissesse seria utilizado contra ele na Justiça". Tal advertência, em termos similares a esse, é conhecida como Miranda Warning e é obrigatória no direito americano por força do precedente *Miranda v. Arizona* (384 U.S. 436, 1966) e inclusive é feita por personagens policiais durante prisões em inúmeros filmes e seriados americanos frequentemente reproduzidos no Brasil. Não é, porém, praxe da polícia militar brasileira a realização de tal advertência quando da prisão-captura em via pública, e menos ainda em tais termos empregados pela testemunha. Daí inclusive haver precedentes bastante recentes declarando a ilicitude de confissão informal colhida pela polícia militar durante a abordagem policial (STF, RHC 170.843 Agr/SP, j. 4.5.2021 e TJSP, Apelação Criminal n. 1500308-45.2020.8.26.0556, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 1º.6.2021). Assim, ao que parece, a testemunha preencheu lacunas de sua memória com informações advindas de fontes diversas, e que não retratam com fidelidade o que ocorreu no momento da abordagem do acusado.

Nesse cenário, de mais a mais, verifica-se que foram arroladas pela defesa apenas familiares do acusado, as quais, compreensivelmente, não têm a imparcialidade necessária para fornecer depoimento isento e confiável em juízo, dada a relação familiar e de afeto com ele mantida. O próprio acusado indicou que havia outros populares no momento da abordagem e inclusive declinou seus nomes, mas nenhum deles foi arrolado e qualificado para viabilizar sua oitiva em juízo. Quanto à ponderação defensiva de que poderiam sentir receio de represálias, embora não se ignore ser comum tal receio em casos como o presente, vale notar que há na legislação instrumentos para a coleta de depoimento em tais situações (Lei n. 9.807/99, Decretos Estaduais n. 44.214/1999 e n. 56.562/2010, Provimento n. 32/00-CGJ/TJSP), mas a defesa nem sequer requereu a sua utilização neste caso.

Portanto, em resumo, em relação à hipótese alternativa sustentada pelo acusado e pelas testemunhas de defesa, não há coerência interna da própria narrativa, tampouco coerência externa com os demais elementos probatórios trazidos aos autos. Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas. Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). o que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, o de transportar, como no caso dos autos.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que o acusado praticou conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n.11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes demonstra a existência de mais de uma condenação penal definitiva (cf. Súmula 444/STJ), a qual também configura reincidência (CP, art. 64). Assim, a fim de evitar punição dúplici pelo mesmo fato (*bis in idem*), uma delas será considerada como reincidência na segunda fase e as demais como antecedentes negativos nesta primeira fase (cf. Súmula 241/STJ e STJ, REsp 1.794.854/DF). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), passa-se ao seu exame.

Quanto à natureza da droga, verifica-se que no caso houve a apreensão de mais uma espécie de substância ilícita (maconha, cocaína e crack), de modo a denotar maior reprovabilidade da conduta e justificar a valoração negativa de tal circunstância nesta fase da dosimetria. Sobre o tema, cf., por todos, STJ, HC 615.347/RS, DJe 15/12/2020. Quanto à quantidade de droga, não houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita suficiente para a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I). Assim, a pena-base deve ser agravada em 1/6 (um sexto), conforme referencial jurisprudencial.

Na segunda fase da dosimetria, não há limites legais mínimo e máximo de agravamento ou atenuação de pena previamente estipulados nos arts. 61 a 66 do CP. Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a aplicação da fração de 1/6 como patamar mínimo das causas de aumento/diminuição de pena constantes do Código Penal, consolidou-se a fixação da fração de 1/6 como referencial para o agravamento ou atenuação da pena em razão de cada circunstância legal, de modo que "a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). Nesse sentido, a orientação é a de que "a reincidência específica autoriza a adoção de fração maior que 1/6 na segunda fase da dosimetria" (STJ, HC 480.406/SC, Sexta Turma, DJe 25/04/2019).

Assim, a pena intermediária é fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mais 729 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva deve ser mantida no patamar da pena provisória.

Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de

reclusão, mais 729 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve ser atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a reincidência do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado, com base no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP e observadas as Súmulas 718 e 719/STF e 269 e 440/STJ.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu em razão da reincidência. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo, em razão da reincidência, diante do supracitado art. 33, § 2º, do CP. Sobre o tema: STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro Sexta Turma, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no HC 567.813/SP, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado RODRIGO DE JESUS DE SOUZA SILVA ao cumprimento de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 729 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do acusado. Recomende-se ré o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único). Quanto à arma de fogo e às munições apreendidas, deve ser decretada a perda em favor da União. Encaminhem-se ao Comando do Exército para destruição, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD

(LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Nazaré Paulista, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA